

1500343-17.2022.8.26.0400

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eduardo Luiz de Abreu Costa

Comarca: Olímpia

Foro: Foro de Olímpia

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/11/2022

... pessoa. Por suspeitar da prática de tráfico ilícito de drogas, acredita."

Pois bem.

#### 2.1.1Do tráfico ilícito de drogas

Nos termos do art. 33, caput, da LD, "importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Olímpia - Vara Criminal

Praça Monteiro Lobato, 377, Centro - CEP 15400-000, Fone:

(17)3281-1927, Olímpia-SP - E-mail: olimpiacr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30 às 19h

1500343-17.2022.8.26.0400 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500343-17.2022.8.26.0400

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Parte processada:

BRENO ANTONIO CARDOSO DA SILVA

#### I - DO RELATÓRIO

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou a parte processada Breno Antonio Cardoso da Silva, devidamente qualificada, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas, LD) (fls. 102/103).

Determinou-se o processamento (fls. 105/107).

A parte processada, devidamente notificada (fls. 156), apresentou resposta escrita (fls. 127/128). Argumentou, ao lado de questões preliminares ao recebimento da denúncia, teses absolutórias (art. 386 do CPP).

Enfrentadas as alegações, a denúncia foi recebida em 8 de julho de 2022 (fls. 148/151) e, conseqüentemente, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento.

A parte processada foi citada pessoalmente (fls. 170).

## II - DOS FUNDAMENTOS

Antes de discutir o mérito, há alegação preliminar.

Nos termos do art. 240, § 2º, do CPP, "proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida; 'coisas achadas ou obtidas por meios criminosos' (art. 240, § 1º, b, do CPP); 'instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos' (art. 240, § 1º, c, do CPP); 'armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso' (art. 240, § 1º, d, do CPP); 'objetos necessários à prova de infração ou à defesa do autuado' (art. 240, § 1º, e, do CPP); 'cartas, abertas ou não, destinadas ao autuado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato' (art. 240, § 1º, f, do CPP); e 'qualquer elemento de convicção' (art. 240, § 1º, h, do CPP)."

A delação anônima (notitia criminis inqualificada) permite que as autoridades policiais e seus agentes realizem diligências preliminares para averiguar se os fatos narrados na denúncia apócrifa são elementos informativos idôneos, ou seja, materialmente verdadeiros (TJSP - 2ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0004636-51.2015.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Pres. Rel. Des. ALEX ZILENOVSKI, V.U., j. 27/11/2017, p. 3).

"A mera alegação genérica de 'atitude suspeita' é insuficiente para a licitude da busca pessoal" (STJ - Sexta Turma - RHC n. 158.580-BA, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, V.U., j. 19/04/2022).

No caso concreto submetido à análise deste magistrado, os agentes do Estado explicaram, com detalhes, o contexto fático anterior à busca pessoal, conforme se verá adiante, que permitiu a conclusão acerca da ocorrência fundada de ocultação de objetos ilícitos, de sorte que reputo lícita a diligência estatal.

### 2.1 Da materialidade dos fatos e da autoria delitiva

A ação penal é procedente.

Certa a materialidade do contexto fático descrito na denúncia, pela leitura do boletim de ocorrência (fls. 06/07 [B0]), do auto de exibição e apreensão (fls. 08 [AEA]) e dos laudos periciais toxicológicos provisório (fls. 10/12) e definitivo (fls. 119/121 [LPTox]), a autoria, conforme prova testemunhal produzida (v. TA), segue a mesma sorte de certeza (demonstração e comprovação).

Contextualizo e, ao final, explico.

A testemunha José Alberto Alves Bitencourt, que é membro da Polícia Militar, declarou, perante a autoridade policial (fls. 03), que: "receberam uma denúncia anônima conhecido como "Nim Bala" estaria vindo de Olímpia em um ônibus da empresa Itamarati com drogas para a cidade de Severínia. Diante das informações, e sabendo de que se tratava de Breno Antônio Cardoso da Silva, vulgo "Nim Bala" conhecido nos meios policiais pela prática do tráfico de drogas, inclusive respondendo dois processos, deslocaram para a entrada da cidade, quando pela Avenida Julian Donaire, depararam com o ônibus da empresa Itamarati, momento em que Breno desceu pela Rua Moacir Costa e foi abordado. Em busca pessoal, nada de ilícito foi localizado, porém em sua mochila foi localizado um tijolo de maconha e a quantia de R\$ 226,00. Indagado, disse que a droga era para uso. Foi dada voz de prisão e Breno algemado, sendo conduzido até este Plantão." Em Juízo, confirmou as suas declarações extrajudiciais.

A testemunha Tiago Alessi, que é membro da Polícia Militar, declarou, perante a

autoridade policial (fls. 02), que: "receberam uma denúncia anônima conhecido como "Nim Bala" estaria vindo de Olímpia em um ônibus da empresa Itamarati com drogas para a cidade de Severínia. Diante das informações, e sabendo de que se tratava de Breno Antônio Cardoso da Silva, vulgo "Nim Bala" conhecido nos meios policiais pela prática do tráfico de drogas, inclusive respondendo dois processos, deslocaram para a entrada da cidade, quando pela Avenida Julian Donaire, depararam com o ônibus da empresa Itamarati, momento em que Breno desceu pela Rua Moacir Costa e foi abordado. Em busca pessoal, nada de ilícito foi localizado, porém em sua mochila foi localizado um tijolo de maconha e a quantia de R\$ 226,00. Indagado, disse que a droga era para uso. Foi dada voz de prisão e Breno algemado, sendo conduzido até este Plantão." Em Juízo, confirmou as suas declarações extrajudiciais.

A testemunha Jhonatan Henrique Rosa Cândido, que é conhecido do acusado, declarou, em Juízo, que: "Não presenciou o contexto fático processado. Relatou, em síntese, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do acusado."

Nos termos do art. 209, § 2º, do CPP, "não será computada como testemunha a pessoa que nada souber que interesse à decisão da causa", de modo que o depoimento desta testemunha "não contribui para o deslinde do feito" (TJSP – 13ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1501168-29.2020.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. MARCELO SEMER, V.U., j. 26/10/2022, p. 06).

O acusado foi ouvido pela autoridade policial (fls. 04).

Negou a prática criminosa.

"Que referente aos fatos informa que estava voltando do trabalho e que havia comprado a droga na cidade de Olímpia, de uma pessoa que não quer declinar o nome e que era para uso durante todo o mês."

Negou, igualmente, em Juízo (v. TA).

"Por ocasião dos fatos, estava a retornar da cidade de Olímpia, onde trabalhava, para Severínia, onde mora, quando, ao descer do ônibus, foi abordado por membros da Polícia Militar. Abordaram-no. De fato, trazia consigo, para consumo pessoal, drogas (maconha). Comprou-as na cidade de Olímpia. Não comercializava drogas. Um dos membros da Polícia Militar inquiridos não gosta da sua pessoa. Por suspeitar da prática de tráfico ilícito de drogas, acredita."

Pois bem.

#### 2.1.1Do tráfico ilícito de drogas

Nos termos do art. 33, caput, da LD, "importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar", configura o crime de tráfico ilícito de drogas.

O tipo penal, vejam, é "importar" (fazer vir; trazer, introduzir mercadorias de outro País), "exportar" (enviar, remeter, vender para fora do País ou do Estado), "remeter" (mandar; enviar; recomendar; fazer entrega; expedir; encaminhar; destinar), "preparar" (aprontar; arranjar; obter [um corpo qualquer] por meio de composição ou decomposição; compor; dosear; urdir; maquinar; pôr em condições de servir; predispor), "produzir" (dar origem a; causar; fabricar), "fabricar" (produzir na fábrica; manufaturar, preparar; inventar; engendrar), "adquirir" (obter; comprar; aquisitar), "vender" (alienar; ceder por certo preço; trocar por

dinheiro; negociar; não conceder gratuitamente; sacrificar por dinheiro ou por interesse; entregar mediante remuneração; dispor do que possui a troco de dinheiro), "expor à venda" (apresentar; mostrar), "oferecer" (dar; facultar; levar à presença de; mostrar), "ter em depósito" (pôr em depósito; armazenar; guardar [em lugar seguro]; dar a guardar temporariamente), "transportar" (conduzir; levar de um lugar para outro; enlevar; arrebatado; transpor), "trazer consigo" (conduzir ou transportar para cá; fazer-se acompanhar), "guardar" (vigiar; vigilar; conservar; manter), "prescrever" (receitar; ministrar), "ministrar" (prestar; fornecer; aplicar), "entregar" (dar; ceder; confiar) "a consumo" (elemento subjetivo específico [pela interpretação contextual]) ou "fornecer" (promover; abastecer; garantir; ministrar; proporcionar ou ministrar o necessário a) "drogas" (as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União [art. 2º da LD]), "ainda que gratuitamente" (animus sine lucro captando), "sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar" (elemento normativo).

A redação do art. 33, caput, da LD, diferentemente do disposto nos arts. 28, caput (porte ilícito de drogas para consumo pessoal), e 33, § 1º, III (utilização ilícita de bem para o tráfico ilícito de drogas ou com o seu consentimento), da LD, não descreve elemento subjetivo específico do tipo, mas há consenso doutrinário (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. – 4.ª edição – São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. BACILA, Carlos Roberto; RANGEL, Paulo. Comentários penais e processuais penais à lei de drogas. – 1.ª edição – Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2007. MORAES, Alexandre de; SMANIO, Gianpaolo Poggio. Legislação penal especial. 7.ª edição – São Paulo: Atlas, 2004. MARCÃO, Renato. Tóxicos: lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006 – nova lei de drogas. – 4.ª edição – São Paulo: Saraiva, 2007. JESUS, Damásio de. Lei antidrogas anotada – comentários à lei n. 11.343/2006. – 9.ª edição – São Paulo: Saraiva, 2009. GOMES, Luiz Flávio; BIANCHINI, Alice, CUNHA, Rogério Sanches, OLIVEIRA, William Terra de. Lei de drogas comentada. 3.ª edição – São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008), referendado pela jurisprudência (STF – Primeira Turma – Habeas Corpus 69.806-GO – Rel. Min. Celso de Mello, DJ, Seção I, 04/06/1993; STJ – Sexta Turma – AREsp 1.790.656-SC – Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, p. 03; TJSP – 2ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0011586-45.2010.8.26.0564 – Rel. Des. Paulo Rossi, V.U., j. 20/06/2011; TJGO – ACrim. n. 33578-9/213 – Rel. Des. Jamil Pereira de Macedo, DJGO 11/11/2008; RT 729/542 e 114/357), de que, para a caracterização do crime de tráfico ilícito de drogas, exige-se a vontade de participar da produção e da circulação de drogas (a intenção de comercializar drogas ilícitas).

Não se exige, todavia, a exteriorização do ato (traditio) concreto de comércio (TJSP – 7ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0002166-76.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. AGUINALDO DE FREITAS FILHO, V.U., j. 21/08/2019, p. 11).

Por se tratar de infração permanente (TJSP – 13ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500168-08.2020.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. XISTO ALBARELLI RANGEL NETO, V.M., j. 18/04/2022, p. 03/04), entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência (art. 313 do CPP).

Das dezoito condutas descritas no art. 33, caput, da LD (tráfico ilícito de drogas), o art. 28, caput, da LD (porte ilícito de drogas para consumo pessoal) descreve cinco idênticas (adquirir, guardar, ter em depósito, transportar e trazer consigo).

Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal (art. 28, caput, da LD), ou alheio (art. 33, caput, da LD), o que não é tarefa fácil, o magistrado atenderá, ao proferir a sentença de mérito, às circunstâncias estabelecidas no art. 28, § 2º, da LD (critérios valorativos), e não ao conhecimento (avaliação pessoal) dos

agentes de segurança pública a respeito da fama da parte ré (odioso critério subjetivo) (STJ - Sexta Turma - AREsp 1.790.656-SC - Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, p. 04).

O magistrado não julga pessoas, mas atos e fatos.

"E a fama está marcada pela ideia de reputação, aquilo que se diz de alguém" (CORTELLA, Mário Sérgio. Pensar bem nos faz bem!: 2. família, carreira, convivência e ética - 3. ed. - Petrópolis, RJ: Vozes, 2015 - São Paulo, SP: Ferraz e Cortella, 2014, p. 105).

Não são excludentes, consigno, os tipos penais relativos ao tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da LD) e ao porte ilícito de drogas para consumo pessoal (art. 28, caput, da LD) (TJSP - 3ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000357-36.2015.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. JAIME FERREIRA MENINO, V.U., j. 10/09/2019, p. 14).

A coincidência das figuras é comum (TJSP - 6ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1501810-36.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. MARCOS ANTÔNIO CORREA DA SILVA, V.U., j. 10/06/2021, p. 08).

"Existe a possibilidade de critério para se imaginar a justeza de uma guerra. Talvez se dissesse que, na guerra contra o tráfico, na guerra contra a bandidagem, na guerra contra a corrupção, aí, sim, há uma justeza porque a causa é nobre" (CORTELLA, Mário Sérgio. Pensar bem nos faz bem!: 2. família, carreira, convivência e ética - 3. ed. - Petrópolis, RJ: Vozes, 2015 - São Paulo, SP: Ferraz e Cortella, 2014, p. 106 [ênfatizei]).

Valho-me, pois, dessa explicação.

Respeitada a versão do acusado, entendo que, confrontada com o quadro de provas produzido, está absolutamente isolada (solitária) e contraditória (contraposta) (TJSP - 3ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 0000109-65.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. XISTO RANGEL, V.U., j. 22/01/2020, p. 05), de modo que as declarações das testemunhas inquiridas, contra quem não há alegação pessoal argüida (TJSP - 9ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 1502980-77.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. SILMAR FERNANDES, V.U., j. 10/02/2020, p. 06), merecem irretocável credibilidade deste magistrado.

Não há motivo fundado para desacreditá-las (TJSP - 7ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 1500329-52.2019.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. FERNANDO GERALDO SIMÃO, V.U., j. 14/10/2021, p. 08; STJ - Quinta Turma - AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO - Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, j. 14/06/2022 ["Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese."]), penso.

Regularmente periciadas (LPTox), as drogas localizadas e apreendidas são proscritas pela Portaria MS/SVS n. 344/1998 - Anexo Lista E, item 1 (CANNABIS SATIVUM [planta que pode originar substância entorpecente ou psicotrópica], conhecida popularmente por maconha).

Nos termos do art. 156, caput, do CPP, a prova da alegação dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor da ação penal (versão exculpatória) incumbe à parte processada e é de inteira e exclusiva responsabilidade sua (TJSP - 2ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 0001619-70.2016.8.26.0400, da

Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. AMARO THOMÉ, V.U., j. 02/09/2019, p. 08; TJSP - 9ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 0000055-02.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. CARLOS EDUARDO ANDRADE SAMPAIO, V.U., j. 30/01/2020, p. 05).

E, nesse aspecto, o acusado, posto alegar, não provou.

A título de argumentação (ad argumentandum), o Excelentíssimo Senhor Desembargador José Damião Pinheiro Machado Cogan anotou que "um cigarro de maconha é confeccionado com 0,5 a 1,0 g do entorpecente, uma fileira de cocaína é confeccionada com 0,100 a 0,125 gramas da droga, aproximadamente" (TJSP - 5ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000638-88.2018.8.26.0588 - Rel. Des. José Damião Pinheiro Machado Cogan, V.U., j. 17/06/2019), de modo que, no presente caso dos autos, as drogas apreendidas não constituem evidentemente pequena quantidade e, de acordo com a experiência forense, são incompatíveis com a hipótese de simples uso (TJSP - 4ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0002613-30.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. ROBERTO PORTO, V.U., j. 10/09/2019, p. 04/05).

Assim, convenço-me que o acusado, nas circunstâncias de tempo e lugar denunciadas, trazia consigo, para consumo alheio (vontade de participar da produção e da circulação de drogas), as drogas apreendidas (AEA [em formato de tablete]), indevidamente (sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar).

Em relação ao contexto fático processado e julgado, saliento, a infração foi cometida em transporte público (ônibus) (art. 40, III, da LD [circunstância descrita na denúncia]), dado que extraio das declarações dos agentes de segurança pública.

De rigor, pois, a condenação do réu.

Eis o meu convencimento.

#### 2.1.2 Das circunstâncias agravantes

Desse contexto, reconheço, embora não tenha sido alegado (art. 385 do CPP) (TJSP - 15ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 1500256-32.2020.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. GILDA CERQUEIRA ALVES BARBOSA AMARAL DIODATTI, V.U., j. 05/08/2021, p. 08 ["não há que se falar em nulidade de capítulo da sentença por violação ao princípio da congruência"]), ter a parte ré cometido o crime em ocasião de calamidade pública (art. 61, II, j, 4ª figura, do CP) (Decreto presidencial n. 10.308, de 2 de abril de 2020) (TJSP - 3ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 1500036-97.2021.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. JAYME WALMER DE FREITAS, V.U., j. 26/04/2022, p. 08; TJSP - 3ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1500574-78.2021.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. TOLOZA NETO, V.U., j. 22/02/2022, p. 09/10; TJSP - 4ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1500095-85.2021.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. EUVALDO CHAIB, V.U., j. 15/12/2021, p. 06/09; TJSP - 6ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1500166-87.2021.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. FARTO SALLES, V.U., j. 09/06/2022, p. 10/11; TJSP - 6ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1501475-80.2020.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ANTÔNIO CARLOS MACHADO DE ANDRADE, V.U., j. 02/12/2021, p. 04; TJSP - 9ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1500770-82.2020.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel.ª Des.ª FÁTIMA GOMES, V.U., j. 31/03/2022, p. 11; TJSP - 10ª Câmara de Direito Criminal - Apelação

Criminal n. 1500422-78.2020.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. LAERTE MARRONE DE CASTRO SAMPAIO, V.U., j. 02/06/2022, p. 15; TJSP – 14ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1500865-15.2020.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. WALTER DA SILVA, V.U., j. 23/02/2021, p. 03; TJSP – 15ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1500639-10.2020.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. RICARDO SALE JÚNIOR, V.M., j. 15/06/2022, p. 15/17), porquanto, ao aproveitar-se da situação trágica (fato que envolve muitas pessoas), demonstrou desprezo (pouco-caso, desamor) solidário e fraternal; enfim, externou insensibilidade coletiva.

O período de restrição sanitária (coronavírus [Covid-19]), mesmo após o término da vigência do Decreto presidencial, perdura infelizmente (TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500574-78.2021.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. TOLOZA NETO, V.U., j. 22/02/2022, p. 09/10; STF – Tribunal Pleno – ADI 6625-DF – Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJ 08/03/2021), de sorte que há possibilidade da aplicação da circunstância agravante.

No entender deste magistrado, a redação do art. 61, II, j, do CP não traz nenhum requisito disciplinador, limitando-se a punir mais gravemente o cometimento do crime em ocasião de calamidade pública (objetividade temporal).

"Trata-se, portanto, de agravante de natureza objetiva" (TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500095-85.2021.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. EUVALDO CHAIB, V.U., j. 15/12/2021, p. 06/09).

## 2.2 Dos elementos do crime

No que se refere ao FATO TÍPICO, a descrição (conduta dolosa – resultados normativo e naturalístico – nexos de causalidade) atribuída à parte ré, contida na denúncia, sem modificá-la (art. 383 do CPP), adequa-se tipicamente (tipicidade), de acordo com os fundamentos desta sentença, no art. 33, caput, c.c. o art. 40, III, da LD.

No que se refere à ILICITUDE, o contexto fático típico (injusto penal) praticado pela parte ré (tráfico ilícito de drogas), em razão da lesão aos bens jurídicos tutelados (a saúde pública, primariamente, e a vida, a saúde pessoal e a família [STF, RT 618/407; TJSP – Câmara Especial – Apelação Cível n. 1500148-37.2019.8.26.0400, do Anexo da Vara da Infância e da Juventude, Atos Infracionais e Medidas Sócio-educativas da Comarca de Olímpia – Rel. Des. RENATO GENZANI FILHO, V.U., j. 15/01/2020, p. 07], secundariamente), é contrário ao ordenamento jurídico, não se identificando, nos autos, nenhuma causa excludente.

A perversidade do tráfico ilícito de drogas destrói a base da sociedade (art. 226, caput, da CF), que, pelos efeitos permanentes (dependências física e psicológica) da infração penal praticada pela parte ré, sente a desordem concreta (palpável).

Sem ordem não há progresso.

No que se refere à CULPABILIDADE, a parte ré era imputável, detinha possibilidade de compreender a ilicitude de sua conduta e, na situação em que se encontrava, podia ser exigido dela comportamento diferente, não se vislumbrando, nos autos, nenhuma causa excludente.

## 2.3 Da aplicação da pena

Esclareço, inicialmente, que a pena-base será fixada (I) atendendo-se aos critérios do art. 59 do CP e art. 42 da LD (denominados pela doutrina de “circunstâncias judiciais”), com preponderância deste em relação àquele (STJ – Habeas Corpus n.

688.099-SP, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS, j. 11/03/2022, p. 04; TJSP - 4ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 1501137-43.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. EDISON APARECIDO BRANDÃO, V. U., j. 22/03/2021, p. 10); (II) em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; (III) por último, as causas de diminuição e de aumento.

Pois bem, considerando o preceito secundário do contexto criminoso processado e julgado - Tráfico ilícito de drogas circunstanciado (art. 33, caput, c.c. o art. 40, III, da LD): 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa -, passo a fixá-lo, pelo princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) (TJSP - 10ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 0000015-59.2014.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. FRANCISCO JOSÉ GALVÃO BRUNO, V.U., j. 23/05/2019, p. 04), particularmente.

Antes, porém, sintetizo os dados processuais da parte ré:

Tempo do fato: 20/03/2022

Folha de Antecedentes

Autos  
(referência)

Data do fato  
(específica)

T. em julgado (processo)

Certidão  
Criminal

T. em julgado (extinção)

Classificação  
penal

\*

0000298-77/2017

04/08/2017

10/02/2021

28

\*

Reincidência  
específica

A considerar esse quadro descritivo (TJSP - 1ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 1500192-56.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. LUIZ ANTONIO FIGUEIREDO GONÇALVES, V.U., j. 08/05/2021, p. 06; TJSP - 6ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 0000753-62.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de

Olímpia - Rel. Des. MARCOS CORREA, V.U., j. 11/07/2022, p. 03/04 ["O magistrado fez uma tabela informando didaticamente quais condenações utilizou para efeito de maus antecedentes e quais utilizou para efeito de reincidência."]), início a dosimetria.

Com relação aos CRITÉRIOS DOS ARTIGOS 59 DO CÓDIGO PENAL E 42 DA LEI DE DROGAS, entendo que, sopesando ambas as disposições legais, (i) a culpabilidade e (ii) a quantidade das drogas são desfavoráveis à parte ré, de modo que fixo a pena-base, majorando-a de 2/6 (dois sextos), em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

A justificar a base penal fixada acima do mínimo cominado, CONSIDERO, atribuindo-se, para cada circunstância, a fração mínima estabelecida pelo Código Penal (1/6) (TJSP - 3ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 0005610-20.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ANTÔNIO ÁLVARO CASTELLO, V.U., j. 28/09/2020, p. 17 [1/6]), os itens judiciais apontados. Explico:

Da culpabilidade: No entender deste magistrado, o contexto criminoso apresenta elevadíssimo grau de reprovabilidade e censurabilidade, na medida em que a localização geográfica do Parque Aquático Thermas dos Laranjais, na região da Comarca da Estância Turística de Olímpia (localizada nas proximidades da divisa dos Estados de São Paulo e Minas Gerais, às margens do Rio Grande), o parque aquático mais visitado do Brasil e da América Latina e o 4º mais visitado em todo o mundo (em 2018, mais de 2,6 milhões de visitantes), ao contrário de outras Comarcas, desperta a prática da traficância, aptidão atrativa (vis attractiva) essa que não pode ser ignorada pelo Estado, de modo a transformar os agentes públicos, no jargão forense, "enxugadores de gelo", pois o comportamento em questão, infelizmente, mostra-se bastante acentuado na região noroeste paulista (TJSP - 2ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0004636-51.2015.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ALEX ZILENOVSKI, V.U., j. 27/11/2016, p. 06; TJSP - 3ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1500225-46.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. JAYME WALMER DE FREITAS, V.U., j. 22/22/2022, p. 08 ["Pondere-se que essa alta culpabilidade, em nosso sentir, deveria caracterizar circunstâncias do crime. Vale dizer, a traficância em local tão visitado merecia majoração desta circunstância, com a devida vênia, pois a comercialização para tamanho público seria bem mais facilitada. De todo modo, o aumento à pena-base tem fundamento e merece ser mantido."]); TJSP - 3ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1500061-32.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ANTÔNIO ÁLVARO CASTELLO, V.U., j. 21/08/2020, p. 08; TJSP - 3ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0005627-90.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO, V.U., j. 31/07/2018, p. 03; TJSP - 4ª Câmara de Direito Criminal - Apelações n. 0002510-23.2018.8.26.0400 e n. 0000218-65.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. LUÍS SOARES DE MELLO NETO, V.U., j. 06/04/2020 e j. 12/10/2019, p. 09, respectivamente; TJSP - 4ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000524-82.2017.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel.<sup>a</sup> Des.<sup>a</sup> IVANA DAVID, V.U., j. 22/10/2019, p. 05; TJSP - 4ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000382-78.2017.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ROBERTO TEIXEIRA PINTO PORTO, V.U., j. 24/09/2019, p. 06; TJSP - 4ª Câmara de Direito Criminal - Apelações n. 1500348-58.2019.8.26.0557 e n. 0000733-71.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. EUVALDO CHAIB FILHO, V.U., j. 15/04/2020 e j. 11/12/2018, p. 05 e 04, respectivamente; TJSP - 5ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0003945-03.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel.<sup>a</sup> Des.<sup>a</sup> CLÁUDIA LÚCIA FONSECA FANUCCHI, V.U., j. 12/02/2019, p. 08; TJSP - 6ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1501167-78.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. FARTO SALLES,

V.U., j. 08/04/2022, p. 10; TJSP - 6ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1501810-36.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. MARCOS ANTÔNIO CORREA DA SILVA, V.U., j. 10/06/2021, p. 09; TJSP - 6ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0003377-84.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. EDUARDO CRESCENTI ABDALLA, V.U., j. 04/11/2020, p. 05; TJSP - 6ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0001150-53.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA, V.U., j. 07/10/2019, p. 04; TJSP - 6ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000097-71.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ANTÔNIO CARLOS MACHADO DE ANDRADE, V.U., j. 31/01/2019, p. 09; TJSP - 7ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1500017-62.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. AGUINALDO DE FREITAS FILHO, V.U., j. 11/04/2022, p. 18/19; TJSP - 7ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0001633-83.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ALBERTO ANDERSON FILHO, V.U., j. 13/03/2019, p. 05; TJSP - 7ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0003837-71.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. EDUARDO CRESCENTI ABDALLA, V.U., j. 23/05/2018, p. 05; TJSP - 7ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0003167-18.2013.8.26.0439, da 1ª Vara da Comarca de Pereira Barreto - Rel. Des. ROBERTO MORTARI, V.U., j. 5/03/2015; TJSP - 8ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1500631-96.2021.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. JUSCELINO BATISTA, V.U., j. 08/08/2022, p. 04 ["A exasperação, calcada no artigo 59 do Código Penal e no artigo 42 da Lei 11.343/06 (Lei de Drogas), se deu mediante fundamentação concreta e idônea, com esteio em dados que exorbitam os limites inerentes ao tipo penal..."]; TJSP - 8ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1500636-21.2021.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel.ª Des.ª ELY AMIOKA, V.U., j. 22/06/2022, p. 12; TJSP - 8ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0001092-50.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ALEXANDRE CARVALHO E SILVA DE ALMEIDA, V.U., j. 06/02/2020, p. 08; TJSP - 8ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000492-77.2017.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. JÚLIO CAIO FARTO SALLES, V.U., j. 26/09/2019, p. 05; TJSP - 8ª Câmara de Direito Criminal - Apelações n. 0001091-36.2016.8.26.0400 e n. 0000995-50.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. SÉRGIO ANTÔNIO RIBAS, V.U., j. 4/10/2018 e j. 12/03/2020, p. 11 e p. 09, respectivamente; TJSP - 9ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1500221-57.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ROBERTO GRASSI NETO, V.U., j. 20/04/2020, p. 07; TJSP - 9ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1502716-60.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ANDRADE SAMPAIO, V.U., j. 06/04/2020, p. 09; TJSP - 9ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000219-84.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ALCIDES MALOSSI JÚNIOR, V.U., j. 31/10/2019, p. 24; TJSP - 9ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1502980-77.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. SILMAR FERNANDES, V.U., j. 10/02/2020, p. 09; TJSP - 9ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1500770-82.2020.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel.ª Des.ª FÁTIMA GOMES, V.U., j. 31/03/2022, p. 10/11; TJSP - 10ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0003374-61.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. FRANCISCO JOSÉ GALVÃO BRUNO, V.U., j. 13/02/2020, p. 04; TJSP - 11ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0005553-02.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ABEN-ATHAR DE PAIVA COUTINHO, V.U., j. 04/09/2019, p. 02; TJSP - 11ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000369-16.2016.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel.ª Des.ª MARIA TEREZA DO AMARAL, V.U., j. 17/10/2018, p. 04; TJSP - 13ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0005390-56.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. RONALDO

SÉRGIO MOREIRA DA SILVA, V.U., j. 06/12/2018, p. 10; TJSP - 14ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1501960-17.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. MIGUEL MARQUES E SILVA, V.U., j. 25/11/2021, p. 06; TJSP - 14ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1500733-06.2019.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. WALTER DA SILVA, V.U., j. 27/02/2021, p. 03 ["havendo ampla fundamentação do Juízo nesse sentido."]; TJSP - 14ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000103-44.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. HERMANN HERSCHANDER, V.U., j. 06/12/2018, p. 04; TJSP - 15ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1501791-30.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. CLAUDIO LIMA BUENO DE CAMARGO, V.U., j. 10/02/2022, p. 03/04; TJSP - 15ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0002764-64.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. CLÁUDIO MARQUES, V.U., j. 29/11/2018, p. 04; TJSP - 16ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0001464-96.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. OTÁVIO AUGUSTO DE ALMEIDA TOLEDO, V.U., j. 07/08/2019, p. 06; TJSP - 16ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0900341-28.2012.8.26.0439, da 1ª Vara da Comarca de Pereira Barreto - Rel. Des. OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO, V.U., j. 11/06/2013).

Os vários julgados mencionados, em apertadíssima síntese, posicionam-se no mesmo sentido, isto é, a circunstância considerada observa o art. 59 do CP e o art. 42 da LD.

Da quantidade das drogas: No entender deste magistrado, a apreensão de expressiva (significativa) quantidade de drogas deve ser considerada (STJ - Habeas Corpus n. 688.099-SP, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Min. MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS, j. 11/03/2022, p. 05; STJ - Quinta Turma - Habeas Corpus 409.324/MS - Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Dje 28/11/2017; TJSP - 1ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0003398-60.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Pres. Rel. Des. PÉRICLES DE TOLEDO PIZA JÚNIOR, V.U., j. 12/08/2019, p. 14; TJSP - 3ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1501484-76.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. JAYME WALMER DE FREITAS, V.U., j. 11/05/2022, p. 14; TJSP - 4ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0002613-30.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ROBERTO PORTO, V.U., j. 10/09/2019, p. 04/05; TJSP - 5ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000638-88.2018.8.26.0588 - Rel. Des. José Damião Pinheiro Machado Cogan, V.U., j. 17/06/2019; TJSP - 5ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0003223-66.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. TRISTÃO RIBEIRO, V.U., j. 5/07/2018; TJSP - 6ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1500166-87.2021.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. FARTO SALLES, V.U., j. 09/06/2022, p. 05/06; TJSP - 7ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0003192-75.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. AGUINALDO DE FREITAS FILHO, V.U., j. 04/09/2019, p. 7; TJSP - 7ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0001633-83.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ALBERTO ANDERSON FILHO, V.U., j. 13/03/2019, p. 5; TJSP - 8ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1500631-96.2021.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. JUSCELINO BATISTA, V.U., j. 08/08/2022, p. 04; TJSP - 9ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1502980-77.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. SILMAR FERNANDES, V.U., j. 10/02/2020, p. 10 [71,900g de maconha]; TJSP - 11ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0005553-02.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel.ª Des.ª ABEN-ATHAR DE PAIVA COUTINHO, V.U., j. 04/09/2019, p. 03; TJSP - 15ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1500647-84.2020.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel.ª Des.ª GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI, V.U., j. 05/07/2022, p. 12 [150g de

maconha]; TJSP – 15ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0002061-02.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. CLÁUDIO ANTONIO MARQUES DA SILVA, V.U., j. 03/10/2019, p. 07).

Com relação às CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES, da leitura dos autos confrontada com os arts. 61, 62 e 65 do CP, a parte ré é reincidente específica (v. quadro descritivo) (arts. 61, I, 63 e 64, I, do CP) e cometeu o crime em ocasião de calamidade pública (art. 61, II, j, do CP), de modo que fixo a pena provisória, com agravamento de 3/6 (três sextos), em 10 (dez) anos de reclusão e 999 (novecentos e noventa e nove) dias-multa.

Respeitado entendimento diverso, o tratamento diferenciado da circunstância agravante da reincidência específica é justo, proporcional, razoável e, sobretudo, constitucional (art. 5º, XLVI, da CF) (TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500225-46.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. JAYME WALMER DE FREITAS, V.U., j. 22/22/2022, p. 08/09 [1/3]; TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1501944-97.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Estância Turística de Comarca de Olímpia – Rel. Des. CÉSAR MECCHI MORALES, V.U., j. 12/01/2021, p. 06; TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0000109-65.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. XISTO ALBARELLI RANGEL NETO, V.U., j. 22/01/2020, p. 08; TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1500270-50.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. EDISON APARECIDO BRANDÃO, V.U., j. 15/03/2022, p. 12 [1/3]; TJSP – 5ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0008312-75.2013.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. MAURÍCIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO, V.U., j. 27/07/2020, p. 09 [1/3]; TJSP – 5ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0003985-48.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel.<sup>a</sup> Des.<sup>a</sup> CLÁUDIA LÚCIA FONSECA FANUCCHI, V.U., j. 24/07/2019, p. 08; TJSP – 6ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1501167-78.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. FATO SALLES, V.U., j. 08/04/2022, p. 12/13 [1/3]; TJSP – 6ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0002059-32.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA, V.U., j. 06/03/2020, p. 05; TJSP – 6ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0000097-71.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. ANTONIO CARLOS MACHADO DE ANDRADE, V.U., j. 31/01/2019, p. 09; TJSP – 7ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0001243-16.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. EDUARDO ABDALLA, V.U., j. 07/08/2019, p. 03; TJSP – 9ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500221-57.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. ROBERTO GRASSI NETO, V.U., j. 20/04/2020, p. 08; TJSP – 9ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0003452-89.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. SÉRGIO COELHO, V.U., j. 7/02/2019, p. 11; TJSP – 10ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500659-35.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel.<sup>a</sup> Des.<sup>a</sup> JUCIMARA ESTHER DE LIMA BUENO, V.U., j. 30/03/2022, p. 05 [1/3]; TJSP – 10ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0003101-19.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. FRANCISCO JOSÉ GALVÃO BRUNO, V.U., j. 23/07/2020, p. 04 [1/3]; TJSP – 11ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0000369-16.2016.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. MARIA TEREZA DO AMARAL, V.U., j. 17/10/2018, p. 04; TJSP – 15ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500920-97.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. CLÁUDIO ANTONIO MARQUES DA SILVA, V.U., j. 30/10/2020, p. 04 [1/3]).

A incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP) no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância (ato de circulação) pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio (Súmula 630 do STJ).

Com relação às CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO, reconheço que a infração foi cometida em transporte público (art. 40, III, da LD), de modo que, nos termos do art. 40 da LD, fixo a pena provisória, aumentando-a de 1/6 (um sexto), em 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1.165 (mil e cento e sessenta e cinco) dias-multa.

A biografia criminal da parte ré impede o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da LD (TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1501721-13.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. EUVALDO CHAIB, V.U., j. 14/07/2021, p. 05).

Em conclusão, nos termos do art. 68, caput, do CP, fixo a PENA DEFINITIVA em 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1.165 (mil e cento e sessenta e cinco) dias-multa, cujo valor diário da multa penal, atendido o disposto no art. 43 da LD (conforme termo de interrogatório), determino em 1/30 (um trinta avos) do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato.

### 2.3.1 Da culpabilidade diferenciada

Não desconheço, registro inicialmente, a causa prevista no art. 40, III, da LD, que estabelece o lugar do cometimento da infração como causa de aumento de pena.

No caso dos autos, as condições geográficas e turísticas da Comarca (movimentação intensa de pessoas) justificam, no entender deste magistrado, a circunstância judicial considerada.

Trata-se de verdadeira aptidão atrativa (vis attractiva).

Explico.

Nos termos do art. 966, caput, do CC, "considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou serviços."

"Quando alguém com vocação para essa atividade identifica a chance de lucrar, atendendo à demanda de quantidade considerável de pessoas, na tentativa de aproveitar tal oportunidade, ele deve estruturar uma organização que produza a mercadoria ou serviço correspondente, ou que os traga aos consumidores" (COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de direito comercial: direito de empresa. 21ª edição – São Paulo: Saraiva, 2009, p. 03).

"O tráfico de drogas é atividade organizada" (TJSP – Câmara Especial – Apelação Cível n. 1502584-95.2021.8.26.0400, do Anexo da Vara da Infância e da Juventude, Atos Infracionais e Medidas Sócio-educativas da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. BERETTA DA SILVEIRA [Presidente da Seção de Direito Privado], V.U., j. 25/02/2022, p. 07).

O traficante, indubitavelmente, exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação – art. 966, caput, do CC – de drogas (art. 1º, parágrafo único, da LD).

A ação – conceitualmente – é empresarial.

Trata-se, deveras, de atividade econômica ilícita.

Alguém duvida disso? Eu não...

Para a exata compreensão da culpabilidade diferenciada, esclareço, a parte ré,

atendendo à demanda de quantidade considerável de pessoas em virtude das condições geográficas e turísticas da Comarca (vis attractiva), na tentativa de aproveitar tal oportunidade, identificou a chance de lucro fácil, o que representa dado inerente (constitutivo, essencial, intrínseco) ao tipo penal previsto no art. 33 da LD (STJ – 6ª Turma – Recurso em Habeas Corpus 146.316 – Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI, V.U., j. 2021), com benefício pessoal, de um lado, e, de outro, malefício de outrem.

É, justamente, esse aproveitamento (beneficiamento, favorecimento) da indústria do turismo local, com reflexo nos Municípios da Comarca (Altair, Guaraci, Severínia, Cajobi e Embaúba, sem deslembrar dos seus Distritos) e naqueles contíguos (Barretos, São José do Rio Preto e Catanduva), que se leva em conta.

Pondero.

O desenvolvimento econômico da Estância Turística de Olímpia é baseado preponderantemente, mas não exclusivamente, na indústria do turismo (setenta por cento, aproximadamente).

Pelo perfil econômico da Comarca, a parte ré poderia exercer profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou serviços lícitos (art. 170, parágrafo único, da CF).

Direcionou, todavia, a ação para a circulação de drogas.

Não se trata de invenção deste magistrado, mas, porque objetivamente envolvido nos casos com a presidência dos processos criminais, sinto e direciono os critérios legais para a realidade local (TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0002510-23.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. LUÍS SOARES DE MELLO NETO, V.U., j. 06/04/2020, p. 12).

A propósito, exemplifico, moradores dos Municípios de Guaraci (autos n. 1501438-87.2019.8.26.0400, n. 1502975-84.2020.8.26.0400 e n. 1501074-81.2020.8.26.0400), Severínia (autos n. 1500443-06.2021.8.26.0400), Cajobi (autos n. 1500470-37.2020.8.26.0557 e n. 1500153-05.2021.8.26.0557) e São José do Rio Preto (autos n. 1501060-63.2021.8.26.0400) dirigiram-se à Estância Turística da Comarca justamente para adquirir drogas para comercializá-las em vossas cidades.

A parte ré é moradora de Severínia-SP.

Nessa perspectiva, cito reportagem da Redação R11 News, publicada no dia 10 de setembro de 2019 (<https://r11news.com/noticias/9746/>), que, a considerar os dados do Estado de São Paulo, comensurou a relação do crime de tráfico ilícito de drogas com o perfil turístico da Comarca:

"E a migração da criminalidade para o interior do Estado fizeram disparar as ocorrências de flagrante por tráfico ilícito de drogas na cidade.

Nos últimos 10 (dez) anos, esse tipo de ocorrência registrou uma alta de 935% (novecentos e trinta e cinco por cento), saltando de 13 (treze) casos em 2008 para 131 (cento e trinta e um) em 2018.

No mesmo período, em todo o Estado de São Paulo, o número de flagrantes por tráfico passou de 24.493 (vinte e quatro mil e quatrocentos e noventa e três) para 48.322 (quarenta e oito mil e trezentos e vinte e dois), alta de 93% (noventa e três por cento).

Com baixos índices de violência, o tráfico ilícito de drogas é o crime que mais mobiliza as Polícias Militar e Civil na cidade.

Em 10 (dez) anos, foram lavrados 2002 (dois mil e dois) flagrantes em Olímpia. Desse montante, 1090 (mil e noventa) casos foram de tráfico ilícito de drogas, o que representa 54% (cinquenta e quatro por cento) do total.

Em todo o Estado, os flagrantes por tráfico respondem por 36% (trinta e seis) dos autos lavrados em Delegacias.  
A diferença pode ser explicada pelo perfil da cidade e pela atuação das forças policiais".

Respeitado entendimento diverso, concluo, a culpabilidade ponderada (art. 59, caput, do CP) – o beneficiamento (aproveitamento, favorecimento) da indústria do turismo local com reflexo nos Municípios da Comarca e naqueles contíguos, repiso – e a causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da LD não são coincidentes (TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500348-58.2019.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. EUVALDO CHAIB, V.U., j. 15/04/2020, p. 07).

#### 2.4Do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade

Em face do princípio da